

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 폭행죄로 1 심에서 징역 1 년을 선고받았다. 갑은 형이 너무 무겁다고 판단하여 항소를 제기하였고, 검사는 이에 대해 항소를 제기하지 않았다. 항소심에서 갑의 형량이 더 무거워질 수 있는지, 그리고 만약 상고를 한다면 같은 규정이 적용되는지에 대해 궁금해졌다.

【질문】 갑이 항소한 사건에서 원심판결보다 무거운 형을 선고할 수 있는가, 그리고 상고의 경우에도 같은 규정이 적용되는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

피고인인 갑이 형량 감경을 목적으로 항소한 사건에서는 원심보다 무거운 형을 선고할 수 없으며, 이는 불이익 변경 금지 원칙에 따른 것입니다. 다만 검사가 피고인에게 불리하게 항소하지 않은 이상, 항소심에서 형이 가중될 여지는 없습니다. 상고심에서도 피고인만 상고한 경우 동일한 불이익 변경 금지 원칙이 적용되어 형이 무거워지지 않습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형사소송법 제 368 조(불이익변경의 금지) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- **조문 원문:** 제 368 조(불이익변경의 금지) 피고인이 항소한 사건과 피고인을 위하여 항소한 사건에 대해서는 원심판결의 형보다 무거운 형을 선고할 수 없다.
- **해설:** 피고인이 항소한 사건과 피고인을 위하여 항소한 사건에 대해서는 원심판결의 형보다 무거운 형을 선고할 수 없도록 규정하고 있습니다. 이 조항은 피고인의 항소권 행사를 보장하기 위해 형량 가중을 금지하는 핵심 규범입니다. 따라서 갑이 단독으로 항소한 경우 원심보다 무거운 징역 형을 선고하는 것은 법적으로 불가능합니다.

▶ 형사소송법 제 372 조(비약적 상고) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- **조문 원문:** 제 372 조(비약적 상고) 다음 경우에는 제 1 심판결에 대하여 항소를 제기하지 아니하고 상고를 할 수 있다.
 1. 원심판결이 인정한 사실에 대하여 법령을 적용하지 아니하였거나 법령의 적용에 착오가 있는 때
 2. 원심판결이 있는 후 형의 폐지나 변경 또는 사면이 있는 때
- **해설:** 제 1 심 판결에 대하여 항소를 제기하지 아니하고 상고를 할 수 있는 특별한 경우를 규정하고 있습니다. 이 조항은 일반적인 상고 절차와는 다른 예외적인 상고 경로를 제시합니다.

▶ 형사소송법 제 373 조(항소와 비약적 상고) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- **조문 원문:** 제 373 조(항소와 비약적 상고) 제 1 심판결에 대한 상고는 그 사건에 대한 항소가 제기된 때에는 그 효력을 잃는다. 단, 항소의 취하 또는 항소기각의 결정이 있는 때에는 예외로 한다.
- **해설:** 제 1 심 판결에 대한 상고가 항소가 제기된 경우 그 효력을 잃는 원칙과 예외를 규정하고 있습니다. 이는 항소와 상고의 병존 시 절차적 우선순위를 명확히 하는 내용입니다.

【결론】

갑이 단독으로 항소한 폭행죄 사건에서는 형사소송법 제 368 조에 따라 원심보다 무거운 형을 선고받을 수 없습니다. 만약 갑이 상고를 제기하더라도 피고인만을 위한 상고이므로 동일한 불이익 변경 금지 원칙이 적용되어 형량이 가중되지 않습니다. 실무에서는 피고인 측의 항소나 상고 시 형량 감경만을 기대할 수 있으므로, 형량 가중을 우려하여 항소를 포기할 필요는 없습니다.

인용 검증: **3/3** 법제처 확인 | 내용 일치: **3/3** | 환각: **0** 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증